

0001341-31.2016.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SEBASTIAO CLARINDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual SEBASTIÃO CLARINDO DA SILVA, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 01/02) que, no dia 17 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001341-31.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001341-31.2016.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SEBASTIAO CLARINDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual SEBASTIÃO CLARINDO DA SILVA, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 01/02) que, no dia 17 de agosto de 2016, em torno das 16 horas, na Rua André Rovai, na via pública, altura do nº. 37, Bonfim, nesta cidade e Comarca de Osasco, SEBASTIÃO CLARINDO DA SILVA, qualificado às fls. 07/08, trazia consigo e vendia drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e

regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 01 (um) invólucro plásticos, tipo "eppendorf", contendo cocaína, no total de 0,24g (vinte e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L (maconha), no total de 2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13, laudo de constatação de fls. 16/18 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Segundo se apurou, na data do ocorrido, policiais civis diligenciaram ao sítio dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, no intuito de inibir tais ações. Um dos agentes de lei, então, passando-se por usuário de entorpecentes, aproximou-se do denunciado, solicitando uma porção de cocaína e outra de maconha, sendo prontamente atendido pelo increpado. Quando o denunciado entregou as drogas, foi abordado pelo outro policial e, em revista pessoal, foi encontrada, em seu poder, a quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), em dinheiro, em notas trocadas, fruto da mercancia espúria de drogas. Questionado, o denunciado confessou, informalmente, aos policiais, que ali estava realizando o comércio de substâncias ilícitas.

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, inclusive o flagrante de venda. A confissão informal e a presença de dinheiro de origem não esclarecida, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

É dos autos que o denunciado ostenta passagens criminais anteriores, contando, inclusive com condenação decretada consoante DCV de fls. 27/37.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05.

Auto de exibição e apreensão às fls. 14/15.

Laudo de constatação às fls. 17/19.

Folha de antecedentes e certidões às fls. 50/55, 75/80, 167/173 e 241/248.

Em sede de audiência de custódia, foi concedida ao acusado liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão (fls. 61/63).

Laudo toxicológico definitivo às fls. 101/103.

Não tendo o acusado sido localizado para ser pessoalmente notificado, segundo o rito especial da Lei de Drogas, foi aplicada a suspensão do processo e da prescrição às fls. 165, na forma do art. 366 do CPP.

Posteriormente, no entanto, o acusado foi notificado (fls. 202/203) e apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 207/212).

Preliminarmente, aduziu a ausência de justa causa, sustentando, especialmente, que os depoimentos dos milicianos devem ser vistos com reserva, posto que, são eles os primeiros interessados em legitimar sua atuação; assim, requereu a rejeição da inicial acusatória com fundamento no art. 395, III, do CPP. Subsidiariamente, no mérito, pugnou pela desclassificação da imputação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público se manifestou acerca do teor da defesa prévia às fls. 215/217.

A denúncia foi recebida às fls. 219/223, mesma oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento presencial para o dia 27 de outubro de 2022, às 11h00.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, ao

final, interrogado.

Em debates, a Acusação pediu a condenação nos termos da inicial.

Em debates a Defesa, por sua vez, sustenta que houve a indução direta da venda do entorpecente. Aduziu que as versões dos policiais em audiência estão dissonante em relação ao que fora dito na fase policial. Apontou que os valores apreendidos não são em notas miúdas.

É relatório.

Fundamento e decido.

O pedido é improcedente.

Em que pese a comprovação da materialidade delitiva da droga apreendida (uma porção de cocaína e uma "trouxa" de maconha), conforme B.O de fls. 11/13, fotografias (fls. 46/49) e laudo químico-toxicológico (fls. 99/103), os fatos, da forma como expostos na inicial e delineados após instrução, não configuram crime.

O Ministério Público imputa duas condutas típicas, quais sejam: que o réu no dia 17 de agosto de 2016, em torno das 16 horas, na Rua André Rovai, na via pública, altura do nº. 37, Bonfim, nesta cidade e Comarca de Osasco, trazia consigo e vendia drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Com efeito, a prova oral demonstra, para além de qualquer dúvida, que a situação de flagrante decorreu de atuação indutiva dos agentes de polícia.

Em resumo, os policiais, em contraditório, afirmavam que voltavam de uma operação e "resolveram" passar no local dos fatos que é conhecido por haver venda de drogas. Pararam a viatura descaracterizada e observaram por 20 a 30 minutos. Viram que pessoas se aproximavam do réu, entregavam algo ao réu e ele também entregava algo. No total umas 4 pessoas. Por esta razão, relatam que a testemunha Fábio, de posse de R\$ 20,00, aproximou-se do réu e pediu uma porção de cocaína ("um pó") e uma de maconha ("uma trouxa"). O réu tirou as drogas do bolso e entregou-as a testemunha. Em revista foi apreendida a quantia de R\$ 130,00. Em acréscimo, a testemunha Fabio relatou que a área é de cortiço e que não tinha certeza que a interação era "relativa a tráfico". "Ele pegava algo e entregava algo". Não havia mais droga com o réu pois "estava no final do expediente e tinha vendido toda a carga que estava com ele". Leandro também confirmou que não foram apreendidas mais drogas.

Pois bem. Em primeiro lugar, ponto importante a ser desde já salientado, é que toda a droga que estava com o réu foi "vendida" para o agente policial. Assim, quanto às condutas de vender verifica-se que houve, de fato, uma indução (provocação) pela testemunha Fabio que se fez passar por comprador da exata quantia de droga que o réu tinha, em tese, no bolso. O réu, ao que parece, possuía uma porção de maconha e outra de cocaína as quais foram, segundo as testemunhas, adquiridas por Fábio.

No tocante a conduta de trazer consigo, não obstante seja crime permanente, não há falar em qualquer consumação pela simples razão de que não havia outra droga a ser posteriormente vendida. Todo desvalor da ação típica esgotou-se no "ato de venda".

Nesse sentido, Fábio induziu (provocou) o agente à prática do crime e, ao mesmo tempo, impediu que o mesmo se consumasse, até porque, mesmo sendo o crime de ação múltipla, impõe a responsabilização por crime único representado pelo ato de venda do total de drogas que estaria, em tese, com o réu.

Ademais, pela quantidade de dinheiro apreendida e, em especial, em cédulas de valor

elevado (50 reais) não há como presumir que teria havido outro ato de traficância anterior. E mais, os próprios policiais não foram assertivos ao ponto de afirmar que o réu estaria, no momento, negociando droga.

Os fatos retratados, os quais configuram verdadeiro “crime de ensaio” estão sob o auspício da Súmula 145 do STF, segundo a qual: “não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Nesse sentido: 4. Prevalece nesta Corte o entendimento de que o flagrante preparado apresenta-se quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante (STJ, HC n. 214.235/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/05/2014, DJe 30/05/2014). Recurso especial improvido. (REsp 1556355/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018).

Ainda, ponto que merece destaque é que os policiais, segundo consta, voltavam de operação e resolveram – sabe-se lá por qual motivo – parar no local dos fatos para observar e viram algumas “interações” do réu com outras pessoas, as quais sequer foram abordadas. E mais, as próprias testemunhas não afirmaram tratar-se de venda de droga.

Sustentam as testemunhas, outrossim, que o réu teria “confessado” a venda de drogas no local dos fatos.

Anote-se que o réu na fase de inquérito manteve-se em silêncio.

Esta “confissão” – somente no local – não pode ser considerada por este Magistrado. Saliente-se que, se nem a confissão em juízo, como único elemento de prova, pode amparar uma condenação, menos ainda uma confissão no momento da prisão, sem observância de garantias constitucionais, não ratificada, ao menos, perante a autoridade policial.

De fato, a confissão no momento da prisão sem a comprovação de que os agentes policiais garantiram ao réu o direito ao silêncio e o direito a não se autoincriminar é eivada de ilicitude.

Anoto, por oportuno, que eventual confissão no local dos fatos não merece valoração judicial, não apenas porque não há segurança quanto às garantias constitucionais de toda e qualquer pessoa que se vê confrontada com a poder persecutório do Estado – especialmente o direito de não produzir prova contra si próprio –, mas também porque na própria delegacia o réu permaneceu em silêncio, como aludido.

Nesse sentido: STF - AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 170.843/SP - REL. MIN. GILMAR MENDES - 2ª TURMA - J. 04/05/2021). Ou ainda: “Apelação. Comércio ilegal de munição. Sentença procedente. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude probatória. Violação ao direito a não autoincriminação. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Aplicação da suspensão condicional do processo. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena no mínimo legal; b) aplicação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Preliminar. Confissão informal quanto à comercialização ilícita das munições. Violação ao direito ao silêncio. Qualquer pessoa tem o direito de permanecer em silêncio, de não declarar qualquer informação que resulte em auto-incriminação. Art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de eficácia imediata, direito que independe de regulamentação por norma infraconstitucional. Necessidade de advertência ao direito ao silêncio em qualquer fase da persecução penal e por

qualquer agente estatal. Precedentes da Suprema Corte norte-americana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos Tribunais Superiores Pátrios. Inadmissibilidade da prova ilícita. (...)” (TJSP - Apelação Criminal nº 1500308-45.2020.8.26.0556 - 16ª Câmara - Rel. Des. . MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI - j. 1.06.2021).

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o acusado SEBASTIÃO CLARINDO DA SILVA da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos. Oficie-se.

Quanto ao dinheiro apreendido, não sendo reclamado em 90 dias a contar do trânsito em julgado, determino a perda em favor do Fundo Nacional de Drogas. Oficie-se.

Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Osasco, 31 de outubro de 2022.